

0000268-51.2018.8.26.0187

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 203/2018 - Delegacia de Polícia de Fartura

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Claudio Rodrigues

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

16/02/2022

Justiça Gratuita

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Centro - CEP 18870-000, Fone: (14) 3382-1855,

Fartura-SP - E-mail: fartura@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0000268-51.2018.8.26.0187

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 203/2018 - Delegacia de Polícia de Fartura

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Claudio Rodrigues

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

16/02/2022

Justiça Gratuita

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Fartura, Estado de São Paulo, na sala virtual de audiência, presente o MM. Juiz Substituto desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Mário Henrique Gebran Schirmer, comigo Escrevente Técnico Judiciário, no final nomeado e assinado, aí, após os pregões legais, verificou-se o comparecimento do DD. Promotor de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Rafael Nogueira Guimarães, da Dra. Barbara Isabel Dealis Passos, defensora do acusado, e das testemunhas arroladas em comum Walter José Nobile e Ari Sebastião da Silva. Ausente o réu Luiz Cláudio Rodrigues, que não foi encontrado para ser intimado. Instalada a audiência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Tendo em vista que, citado, alterou o réu seu endereço, sem comunicação ao Juízo, nos termos do artigo 366 do CPP, declaro sua revelia.". Em seguida, pelo DD. Juiz foram inqueridas as testemunhas presentes, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Na sequência, ante a impossibilidade de realização do interrogatório em decorrência da ausência do réu, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e perguntado às partes se havia algum requerimento de diligências, nos termos do artigo 402 do CPP, sendo que não houve qualquer requerimento, passando-se então aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi feita a seguinte manifestação, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, foi dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) do réu, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Posteriormente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Trata-se de processo-crime instaurado, por denúncia do Ministério Público, em desfavor de LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES, já qualificado, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art; 12, caput, da Lei 10.826/03.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

"(Fato 1) Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 27 de fevereiro de 2018, durante a manhã, na Rua Sebastião Rodrigues do Amaral, n.º 07, casa 02, centro desta cidade e comarca de Fartura/SP, LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES, qualificado a fls. 25/28, trazia consigo e tinham em depósito, para fins de venda e comercialização, 02 (duas) pedras de crack com peso bruto total de 3,9g e 01 (uma) trouxinha com cocaína, pesando 5,1g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo pericial de fls. 55/57 e 58/60, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Fato 2) Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicados, LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES mantinha sob sua guarda, 25 (vinte e cinco) munições de calibre .12; 01 (uma) munição de calibre .36; e 02 (duas) munições de calibre .38, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que Policiais Civis dirigiram-se até a casa do denunciado para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, conforme decisão copiada a fls. 23/24. Em revista pessoal, no bolso do denunciado, foi encontrada uma pedra de crack. No colchão do quarto, uma pedra menor da mesma droga, ainda, foi encontrada uma trouxinha contendo a cocaína descrita. Por fim, no quarto do denunciado, foram encontradas as munições acima mencionadas. A natureza e quantidade das drogas, circunstâncias que envolveram a

prisão, forma de acondicionamento dos entorpecentes, prontos para a venda, comprovam a prática da traficância e seu dolo. Os laudos periciais juntados a fls. 67/72 comprovaram a eficácia das munições apreendidas." (fls. 161-162).

O acusado foi preso em flagrante, sendo concedida liberdade provisória, em audiência de custódia (fls. 144-145)

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 189-191).

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2020 (fl. 206). Posteriormente, foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 216-219).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela parcial procedência da ação, ao argumento de que devida a desclassificação da imputação do art. 33, caput, da Lei de Drogas, para a conduta do art. 28, da Lei 11.343/06. A respeito da dosimetria, postulou pela valoração dos antecedentes, circunstâncias do crime e reincidência do acusado, alegando, ainda, que impossível a aplicação dos art. 44 e art. 77, do CP.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais sustentando que devida a desclassificação em relação a imputação do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei de Drogas. Quanto ao crime do art. 12, da Lei 10.826/03, alegou a existência de causa excludente da antijuridicidade, ao argumento de que o acusado estaria sendo ameaçado pelo proprietário de sua residência, o Sr. Rafael (vulgo Ratinho).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, possível o julgamento do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt).<https://www.google.com.br/search?>

q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

"DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. A falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente." (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)

"Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida." (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP". (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaquei).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática do delito imputado ao réu. 3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que materialidades e autorias restam demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12-14), Auto de Constatação Preliminar (fls. 15-16),

laudos periciais (fls. 68-69; 70-71; 72-73; 151-156), foto (fl. 105) e, ainda, pela prova oral produzida em juízo.

4. Passo à análise da autoria.

Nesse contexto, as testemunhas Ari e Walter (policial civil) narrou, em síntese, que foram realizar uma busca e apreensão e um mandado de prisão em desfavor do acusado. Ao chegarem na residência do acusado, confirmaram que o acusado tinha em sua residência porções de droga, crack e munições. Disse que as investigações iniciaram porque o acusado teria ameaçado sua ex-companheira e também haviam informações de que seria traficante. O acusado disse que as drogas eram para uso próprio e as munições mantinha como favor para Rafael (rato), com quem tinha uma dívida de tráfico. Afirmou que Rafael é conhecido por ser traficante.

5. Diante deste cenário, entendo que ficaram comprovadas autorias e materialidades.

No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas. Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

“3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).” (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

No caso, os policiais foram inequívocos ao apontar que o acusado tinha, em sua residência, as munições e drogas apreendidas nos autos. A versão está amparada pelas demais provas dos autos. Em contrapartida, não há nada que desabone a versão dos depoentes.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autorias e materialidades da conduta descrita na exordial.

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: “Art.33:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor

a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (grifo nosso).

In casu, não restou devidamente comprovado que o acusado possuísse as drogas para distribuição a terceiros, havendo, pois, 'dúvida razoável' a respeito da efetiva ocorrência sobre a traficância. Isto porque, considerando as frágeis circunstâncias que, em tese, indicariam o acusado como sendo 'traficante' e a pequena quantidade de drogas, é, ao menos, possível considerar a hipótese de que as drogas apreendidas fossem, efetivamente, para consumo pessoal.

É dizer: embora o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresente um tipo plurinuclear alternativo, faz-se necessária a comprovação do dolo na prática da traficância – isto é, a demonstração de que o agir nuclear do tipo se orienta pela finalidade do cometido do ato de tráfico de drogas. Tal situação não restou demonstrada nos autos.

Portanto, devida a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei 11.343/06.

6.1.1. No ponto, ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido que a tipificação estabelecida no art. 28, da Lei 11.343/06, padece de inconstitucionalidade, na medida em que, em decorrência do princípio da lesividade/ofensividade penal – o qual decorre diretamente do direito de liberdade, previsto no art. 5º, caput, e X, da CF –, é incompatível com a ordem constitucional a criminalização de condutas que não atinjam bens jurídicos de terceiros.

É que, conforme bem expos John Stuart Mill, em seu célebre ensaio Sobre a Liberdade: “só o dano para os interesses de outros – ou a probabilidade elevada de haver dano – pode justificar a interferência da sociedade” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 86).

“Nenhuma pessoa devia ser punida simplesmente por estar bêbada; mas um soldado ou um polícia devia ser punido por estar bêbado em serviço. Resumindo: sempre que há um dano claro, ou um risco claro de dano, quer para um indivíduo quer para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no da moralidade ou da lei.

Mas em relação ao dano meramente contingente ou, como pode ser chamado, estrutural, que uma pessoa causa à sociedade através de conduta que nem viola qualquer dever específico para com o público, nem dá azo a danos perceptíveis para qualquer indivíduo definido senão ela mesma, a sociedade pode dar-se ao luxo de suportar essa inconveniência, tendo em vista o bem maior da liberdade humana. Se fosse para punir adultos por não tomarem bem conta de si, preferia que fosse para seu próprio bem, e não com o falso pretexto de os impedir de diminuir a sua capacidade de prestar à sociedade benefícios que esta não finge ter o direito de exigir. Mas não posso aceitar discutir o assunto como se a sociedade não tivesse quaisquer outros meios de elevar os seus membros mais fracos ao padrão normal da conduta racional, a não ser esperar que fizessem algo irracional, e depois puni-los, legal ou moralmente, por isso.” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 77).

A posição não é distinta na doutrina jurídica.

Conforme exposto, pelo Prof. Salo de Carvalho, em sua tese de mestrado, A Política Criminal de Drogas no Brasil:

“O princípio da lesividade ou da ofensividade complementa, de forma organizativa, o princípio da intervenção mínima. O princípio dispõe que somente poderá ser aplicada penalidade no momento em que a ação infrinja bem jurídico determinado, produzindo-lhe dano - resultado material. Quatro funções específicas são delineadas pelo princípio da lesividade, segundo Nilo Batista: a. proibição de incriminações de atitudes internas; b. proibição de criminalizar condutas que não excedam o âmbito do próprio autor; c. proibição de incriminações de simples estados ou condições existenciais; e, d. proibição de criminalização de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico específico. [...].

Sobre a incriminação de atos que não excedam o próprio autor, o princípio se refere

à proibição de incriminação de autolesões, crimes impossíveis e atos preparatórios. Relativo ao caso das drogas, toma-se questão fundamental a análise do bem jurídico tutelado e a potencialidade da lesão, principalmente nas condutas usuais.” (CARVALHO, Salo. A Política de Drogas no Brasil, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da UFSC, 1996, p. 108-109 – negrito original, grifos próprios).

Também nesse sentido:

“A despeito da importância dada por alguns autores funcionalistas ao conceito de bem jurídico para a afirmação da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, a existência e tutela penal do bem jurídico somente tem importância se esse conceito for considerado em conjunto com a ofensividade mínima que se exige para a caracterização da tipicidade material do delito (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 212). [...].

Em face do princípio da lesividade ao bem jurídico, para E. Raúl Zaffaroni, são ilegítimas incriminações penais que imponham uma determinada moral ou que tenham conteúdo simbólico (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 221). Postula também a ilegitimidade do uso da legislação penal a situações em que, embora absolutamente ineficaz para os resultados a que se destina, talvez até mesmo agravando-os, o legislador utiliza-a para tranquilizar a opinião pública e de este modo, proveer al clientelismo político (ZAFFARONI, et all, 2002, p. 489).

Nesse sentido, é de reconhecer-se como função da ofensividade a limitação ao Poder Legislativo, uma vez que devem ser consideradas inconstitucionais as intervenções penais que criminalizam condutas que não ofendem ou sequer geram perigo concreto de lesão a bens jurídicos.

Esses limites impostos ao legislador quando da incriminação de condutas foram sistematizados por Nilo Batista, ao afirmar que o princípio da lesividade tem as seguintes funções: a) proibir a incriminação de uma atitude interna; b) proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; c) proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais; e d) proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico, tendo-se por desviada a conduta fortemente desaprovada pela coletividade (BATISTA, 1999, p. 92 e ss).

De fato, não se pode deixar de constatar a inconstitucionalidade de intervenções estatais desse jaez, na medida em que a Constituição consagra o direito à liberdade de opinião e de expressão (art. 5º, IV, VI), a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X) e o pluralismo político e social (art. 3º, IV).

Assim, manifesta-se a inconstitucionalidade de intervenções estatais com tais conteúdos na medida em que reduzem direitos fundamentais, sem que qualquer finalidade social possa ser antevista nessas intervenções. As intervenções estatais são inconstitucionais se não tiverem por finalidade assegurar os objetivos da República Federativa do Brasil expressos no art. 3º da CR/88. Pelo contrário, o que se vislumbra em incriminações sem ofensa a bens jurídicos é que elas não apenas distanciam a sociedade brasileira de uma sociedade livre (art. 3º, I, CR/88) como ainda ampliam a marginalização, que é objetivo estatal eliminar (art. 3º, III, CR/88). Não se pode perder de vista que: O mais importante compromisso vinculador da atuação do Estado brasileiro decorrente da natureza de nossa Constituição (pacto social) é o reconhecimento da existência de um núcleo inviolável de direitos, constituído pelos direitos fundamentais, cuja tutela é prioridade máxima do Estado e que não podem ser suprimidos nem mesmo a pretexto de atender à vontade da ampla maioria ou ao consenso existente na sociedade. (BRODT, 2005, p. 33).” (ÁREDE, Sirlene Nunes. O Princípio da Ofensividade e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in: Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 55, p. 36-45, out./dez. 2011, p. 37-38).

Além disso, não se pode olvidar que tramita, perante o Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE 635659), com questão de repercussão geral reconhecida, em que se discute a constitucionalidade da previsão normativa do art. 28, da Lei 11.343/06.

É certo que o caso ainda está pendente de julgamento definitivo. Porém, é igualmente inequívoco que os Ministros Gilmar Mendes (relator), Luís Roberto Barroso e Edson Fachin já proferiram votos no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade.

Neste contexto, transcreve-se trecho paradigmático do voto do Ministro Relator: “Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação.

A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais.

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação.

O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita.

Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. São ilustrativos, nesse sentido, os exemplos citados por DANIEL PRADO (Boletim, IBCRIM, outubro/2012, p. 8-9), verbis: [...].

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde.

Não chego ao ponto de afirmar que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito. Cabe registrar que, com esse mesmo entendimento, a Corte Constitucional alemã negou, em 1994, no julgamento do caso Cannabis, a existência de semelhante direito (Recht zum Rausch), afirmando, com isso, a viabilidade da criminalização do tráfico de cannabis sativa (BverfGE 90,145, 9.3.1994).

Também explicitou que o art. 2, I, da Lei Fundamental alemã, assegura o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, mas que o uso de drogas, em especial graças à forte repercussão social que tem, não pode estar nele incluído. Não haveria, assim, um direito a “ficar intoxicado” (“Recht auf Rausch”) assegurado pela Lei Fundamental.

O Tribunal considerou, todavia, que casos envolvendo posse, compra ou importação de pequenas quantidades de maconha para uso eventual devem ser desconsiderados pela insignificância de culpa e da proporção do dano causado.

De forma resumida, o §31 da lei alemã sobre narcóticos (“Betäubungsmittelgesetz”) estabelece que a posse de pequenas quantias de drogas pode não ser criminalizada, exceto em caso de interesse público, e autoriza os promotores a encerrar o caso sem consultar o Judiciário.

Ainda que se afirme que a posse de drogas para uso pessoal não integra, em sua plenitude, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, isso não legitima que se lance mão do direito penal para o controle do consumo de drogas, em prejuízo de tantas outras medidas de natureza não penal, como, por exemplo, a proibição de consumo em lugares públicos, a limitação de quantidade compatível com o uso pessoal, a proibição administrativa de certas drogas sob pena de sanções administrativas, entre outras providências não tão drásticas e de questionáveis efeitos como as sanções de natureza penal.

Na Espanha, por exemplo, entre as sanções administrativas previstas na legislação,

há multas de até 30 mil euros e/ou a suspensão da carteira de motorista. São medidas, como se percebe, bem mais eficazes na contenção do consumo do que a simples aplicação de medidas penais sem resultados práticos demonstráveis. Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art. 4º da Lei 11.343/06 – é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas.

Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade.

Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social.

A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal.

Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.” (Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, no RE 635659 – grifos próprios).

Não distinto foi o posicionamento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

“VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO

Do ponto de vista jurídico, há pelo menos três fundamentos que justificam e legitimam a descriminalização à luz da Constituição:

1. Violação ao direito de privacidade

A intimidade e a vida privada, que compõem o conteúdo do direito de privacidade, são direitos fundamentais protegidos pelo art. 5º, X da Constituição. O direito de privacidade identifica um espaço na vida das pessoas que deve ser imune a interferências externas, seja de outros indivíduos, seja do Estado. O que uma pessoa faz na sua intimidade, da sua religião aos seus hábitos pessoais, como regra devem ficar na sua esfera de decisão e discricionariedade. Sobretudo, quando não afetar a esfera jurídica de um terceiro.

Ex. É preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, bebe até cair desmaiado na cama, isso não parece bom, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se imiscuir nessa área.

2. Violação à autonomia individual

A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, todavia, absoluta, ela pode ser restringida pela lei. Porém, a liberdade possui um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia individual. Emanação da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções do bem e do bom. Cada um é feliz à sua maneira. A autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.

Exs mais óbvios: o Estado e a sociedade não podem decidir com quem você vai se casar, qual deve ser a sua religião ou que profissão você vai seguir.

As pessoas têm, igualmente, o direito de escolher os seus prazeres legítimos. Há

quem faça alpinismo, voe de ultraleve, participe de corridas de automóvel, ande de motocicleta ou faça mergulho submarino. Todas essas são atividades que envolvem riscos. Nem por isso são proibidas. O Estado pode, porém, limitar a liberdade individual para proteger direitos de terceiros ou determinados valores sociais. Pois bem: o indivíduo que fuma um cigarro de maconha na sua casa ou em outro ambiente privado não viola direitos de terceiros. Tampouco fere qualquer valor social. Nem mesmo a saúde pública, salvo em um sentido muito vago e remoto. Se este fosse um fundamento para proibição, o consumo de álcool deveria ser banido. E, por boas razões, não se cogita disso.

Note-se bem: o Estado tem todo o direito de combater o uso, fazer campanhas contra, educar e advertir a população. Mas punir com o direito penal é uma forma de autoritarismo e paternalismo que impede o indivíduo de fazer suas escolhas existenciais. Para poupar a pessoa do risco, o Estado vive a vida dela. Não parece uma boa ideia.

3. Violação ao princípio da proporcionalidade

O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, na sua dimensão instrumental, funciona como um limite às restrições dos direitos fundamentais. Para que a restrição a um direito seja legítima, ela precisa ser proporcional. Em matéria penal, tal ideia se expressa em alguns conceitos específicos, que incluem a lesividade da conduta incriminada, a vedação do excesso e a proibição da proteção deficiente.

O denominado princípio da lesividade exige que a conduta tipificada como crime constitua ofensa a bem jurídico alheio. De modo que se a conduta em questão não extrapola o âmbito individual, o Estado não pode atuar pela criminalização. O principal bem jurídico lesado pelo consumo de maconha é a própria saúde individual do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Há quem invoque a saúde pública como bem jurídico violado. Em primeiro lugar, tratar-se-ia de uma lesão vaga, remota, provavelmente em menor escala do que, por exemplo, o álcool ou o tabaco. Em segundo lugar porque, como se procurou demonstrar, a criminalização termina por afastar o usuário do sistema de saúde, pelo risco e pelo estigma. De modo que pessoas que poderiam obter tratamento e se curar, acabam não tendo acesso a ele. O efeito, portanto, é inverso. Portanto, não havendo lesão a bem jurídico alheio, a criminalização do consumo de maconha não se afigura legítima.

O teste da proporcionalidade inclui, também, a verificação da adequação, necessidade e proveito da medida restritiva. A criminalização, no entanto, não parece adequada ao fim visado, que seria a proteção da saúde pública. Não apenas porque os números revelam que a medida não tem sido eficaz – o consumo de drogas ilícitas, inclusive da maconha, tem aumentado significativamente –, como pelas razões expostas acima: a saúde pública não só não é protegida como é de certa forma afetada pela criminalização.

A questão da necessidade poderia ser disputada. Há países que optam por criminalizar a maconha. Mas em número decrescente. Na América Latina, como visto, somente Brasil, Suriname e Guianas tratam o porte de drogas para uso pessoal como crime. Existem alternativas que vão desde a previsão de sanções administrativas até o combate via contrapropaganda e cláusulas de advertência.

Mas é sobretudo no terceiro subprincípio – o da proporcionalidade em sentido estrito –, quando se vai aferir o custo benefício da criminalização que a desproporcionalidade se evidencia de maneira mais contundente. O custo tem sido imenso – em recursos drenados para a repressão, para o sistema penitenciário, nas vidas de jovens que são destruídas no cárcere, no poder do tráfico sobre as comunidades carentes – e os resultados têm sido pífios: aumento constante do consumo.

Em suma: por ausência de lesividade a bem jurídico alheio, por inadequação, discutível necessidade e, sobretudo, pelo custo imenso em troca de benefícios irrelevantes, a criminalização não é a forma mais razoável e proporcional de se lidar com o problema.

Pelos mesmos fundamentos, declaro a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 1º do artigo 28 da Lei n 11.343/2006, o qual prevê que se submete às mesmas penas

do caput, “quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”. Aqui, à falta de um critério específico para delimitar o que seja pequena quantidade para consumo pessoal, utilizo o parâmetro adotado no Uruguai, que é de 6 (seis) plantas fêmeas.” (Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no RE 635659 – negritos originais, grifos próprios).

Entretanto, é fato que não existem precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. Ao contrário, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a constitucionalidade da norma supracitada. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Sentença que desclassificou a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas e reconheceu sua inconstitucionalidade – Recurso Ministerial – De rigor a inversão do decisor – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1500247-53.2021.8.26.0556; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021).

“Apelação criminal – Porte de drogas para uso próprio – Juizado Especial de origem que declinou sua competência para a Justiça Comum de Primeiro Grau, diante da impossibilidade de localização do réu – Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade, seja por inconstitucionalidade do art. 28, da Lei de Drogas, ou por aplicação do dito 'princípio da insignificância'. Ausência de recurso Ministerial. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) – Acusado que, na fase extrajudicial, assumiu a posse do entorpecente, não tendo comparecido em Juízo, onde foi decretada a sua revelia – Depoimento seguro do Policial Militar em Juízo confirmando a localização de entorpecentes na residência do réu – De rigor a manutenção da condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. 'Princípio da insignificância' – Impossibilidade de reconhecimento – Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Inconstitucionalidade não reconhecida – conduta despenalizada, mas que permanece criminalizada pela Lei nº 11.343/06. Dosimetria – Patamar das penas de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa que não comporta reparos, especialmente em face da reincidência advinda de tráfico privilegiado. Recurso Defensivo desprovido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500668-61.2018.8.26.0099; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021).

“Posse de maconha – Insignificância do ato – Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – Inexistência – Condenação mantida; Furto qualificado – Escalada – Ausência de laudo pericial – Não caracterização – Inteligência do art. 158, do Código de Processo Penal; Furto – Multirreincidência – Confissão – Preponderância da agravante sobre a atenuante – Impossibilidade – Compensação integral – Não cabimento – Recurso provido em parte para redução da pena.” (TJSP; Apelação Criminal 1501253-43.2020.8.26.0617; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021).

Portanto, considerando os reiterados julgados do e. TJ-SP reconhecendo a constitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06, bem como considerando que ainda está pendente de julgamento definitivo, – a despeito de votos já proferidos – o RE 635659, que tramita no Supremo Tribunal Federal, ressalvo meu entendimento pessoal e deixo de reconhecer a inconstitucionalidade da previsão normativa em comento.

6.2. Em relação a posse de arma de uso permitido, o art. 12, da Lei 10.826/03, determina como delituosa a conduta de: “Possuir ou manter sob sua guarda arma de

fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.

Trata-se de delito de mera conduta e perigo abstrato e que, portanto, se consuma com o simples fato de o acusado ter em sua posse, em casa ou local de trabalho, armamento ou munição de uso permitido, que apto à realização de disparos.

No caso em análise, o crime restou comprovado, atraindo a incidência do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, dado que os relatos apresentados nos autos comprovam que o acusado tinha, em sua residência, 25 (vinte e cinco) munições de calibre .12; 01 (uma) munição de calibre .36; e 02 (duas) munições de calibre .38,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, a capacidade dos artefatos para a realização de disparos está demonstrada por meio dos laudos periciais de fls. 68-69; 70-71; 72-73.

Nesse contexto, tratando-se de delitos de mera conduta, perigo abstrato e estando comprovado que o réu efetivamente possuía os artefatos em contrariedade a determinação legal, está demonstrada a tipicidade das ações.

7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que os réus são imputáveis, têm a consciência da ilicitude de suas ações, lhes era exigível conduta diversa e não agiam amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

Destaque-se que no caso não há de se falar em estado de necessidade, legítima defesa ou, ainda, quando outra causa excludente e ilicitude ou culpabilidade. Isto porque a situação de que o acusado estaria sofrendo ameaças não restou comprovada.

Ao contrário, ainda que a pessoa de Rafael (Ratinho) tenha sido mencionada nos autos, não há qualquer informação concreta de que estivesse ameaçando o acusado.

Ainda mais, mesmo que comprovada a situação, inexistiria estado de necessidade ou outra circunstância que exima o acusado de responsabilidade penal, haja vista que outras alternativas lícitas, ainda seriam possíveis.

Ante o exposto, restou claramente demonstrado que o acusado LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES realizou condutas típicas e antijurídicas, subsumíveis aos tipos penais indicados no art. 28, da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03.

8. Passo à dosimetria da pena.

O delito do art. 12, da Lei 10.826/03, estabelece pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

O art. 28, da Lei de Drogas, não estabelece pena privativa de liberdade, antes fixado como possíveis sanções: (i) advertência sobre os efeitos das drogas; (ii) prestação de serviços à comunidade; (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Por esta razão, a dosimetria não se submete a disposição do art. 68, do CP, sendo realizada a parte.

8.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social, o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A respeito dos antecedentes, observa-se que o acusado apresenta diversas condenações penais com trânsito em julgado (fls. 2492-57). Desta maneira, considerando o art. 68, do CP, que impõe o regime trifásico para a dosimetria, a sentença dos autos 0000034-06.2017.8.26.0187 (art. 129, §9º, e art. 147, ambos do CP) será avaliada a título de reincidência, na segunda fase da dosimetria, e as demais serão ponderadas neste momento.

As circunstâncias pesam em desfavor do acusado em relação ao crime do art. 12, da Lei de Armas, haja vista a diversidade e quantidade de munições apreendidas em sua residência (25 munições de calibre .12; 01 munição de calibre .36; e 02 munições de calibre .38).

A culpabilidade é também neutra.

Desta maneira, conforme o exposto acima, fixo a pena base em: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 16 (dezesesseis) dias-multa, pelo crime do art. 12, da Lei 10.826/03.

8.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes. O acusado é reincidente, na forma do art. 63, do CP, conforme exposto acima. Não há atenuante. Assim, considerando as reincidências e a ausência de atenuantes, exaspero as penas em 1/6 (um sexto). Dessa maneira, as penas intermediárias ficam em: 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 19 (dezenove) dias-multa, pelo crime do art. 12, da Lei 10.826/03.

8.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição. In casu, não se vislumbra nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Pelo exposto, as penas definitivas ficam em: 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 19 (dezenove) dias-multa, pelo crime do art. 12, da Lei 10.826/03.

9. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a reincidência dos acusados, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena de detenção – sem prejuízo de eventuais unificações a serem realizadas pelo juízo de execução competente.

Fixa-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela do TJ-SP, uma vez que não há nos autos informações que permitam arbitramento em outro valor.

10. A respeito da fixação de sanção, em relação ao tipo do art. 28, da Lei

11.343/06, considerando o preceito secundário da norma, a previsão do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 e, ainda, sopesando a circunstâncias do caso (acusado com diversos antecedentes e ainda praticando, ao mesmo tempo, outro delito), entendo que a medida mais adequada é a de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, a ser cumprida em instituição designada pelo juízo da execução, na razão de 04 (quatro) horas de serviço por semana, sendo cumprida, preferencialmente, sem prejuízo do labor do condenado.

11. Em vista dos antecedentes do acusado (multireincidente) e das demais características do caso, inviável a aplicação dos art. 44 e art. 77, do CP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 387, do CPP, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES, pela prática dos delitos previstos no art